

1530928-20.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... o local trata-se de um ponto de tráfico de drogas. Portanto, decidiram por abordar o indivíduo. Foi encontrada uma quantidade de drogas e dinheiro nos seus bolsos. Na sacola preta que havia sido dispensada, havia porções de lança perfume. O réu não resistiu à prisão e confessou a prática do tráfico de drogas. Foram encontrados, ao todo, no bolso direito do réu, cinco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530928-20.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530928-20.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2348007/2021 - 08º D.P. BRAS, 22089755 - 08º D.P. BRAS, 6847/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2348007 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FRANCISCO ALEXANDRE SOUSA VIANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

Francisco Alexandre Souza Viana, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, em 22/12/2021, por volta das 07h20min, na Praça Ouvidor Pacheco e Silva, Sé, São Paulo-SP, o réu trazia consigo e guardava, para venda ao consumo de terceiros, cinco porções de cocaína, com peso líquido de 2,4g (dois vírgula quatro gramas), dez frascos de lança-perfume, todos com 90ml (noventa mililitros) e dez porções de maconha, com peso líquido de 17,2g (dezessete vírgula dois gramas), substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, o réu, que é reincidente específico, trazia consigo em uma

sacola plástica os dez frascos de lança-perfumes e, em seus bolsos, as cinco porções de cocaína e dez porções de maconha, com a finalidade de traficância. Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, momento no qual avistaram o réu que, ao vislumbrar a presença policial, jogou a sacola com os frascos de lança-perfume no chão, vindo a ser abordado.

Uma vez realizada revista pessoal, em poder do réu os agentes localizaram as cinco porções de cocaína e dez porções de maconha, separadas para a venda. Indagado, o réu confessou informalmente que venderia cada embalagem de lança-perfumes por cinco reais, cada porção de maconha por dez reais e cada porção de cocaína por dez reais. Preso em flagrante e conduzido até o distrito policial, em sede de interrogatório o réu confessou.

Eis o teor da denúncia.

O réu foi preso em flagrante em 22/12/2021 (fls. 12).

Em 23/12/2021, a autoridade judicial de plantão homologou a prisão em flagrante do réu e a converteu em prisão preventiva (fls. 50/54).

Após oferecida a denúncia pelo Ministério Público (fls. 74/75), o réu foi notificado (fls. 98) e apresentou a sua defesa prévia (fls. 102/103).

A denúncia foi recebida em 14/02/2022 (fls. 104).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 18/02/2022, foram inquiridos os policiais militares Giovane de Souza da Silva e Felipe de Palma Medeiros. Em seguida, foi designada audiência em continuação para 11/03/2022 (fls. 105).

Aberta a audiência em continuação na data previamente designada, o réu foi interrogado. Ao final, determinou-se a juntada do laudo pericial no prazo de cinco dias e a conversão dos debates em memoriais (fls. 131).

O Ministério Público, em memoriais, pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta descrita na denúncia. Quanto à dosimetria da pena, sustentou a reincidência específica do réu, o não reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, por ter sido apenas parcial, a não aplicação da causa de diminuição de pena do artigo § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 139/143).

Por seu turno, a Defensoria Pública, em memoriais, clamou pela absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, manifestou-se pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e, em caso de condenação pelo crime de tráfico de drogas, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, pela aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e, por fim, pela concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 12), pelo boletim de ocorrência nº BD5122-1/2021 (fls. 33/35), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), pelas fotografias de fls. 30/31, pelo laudo pericial de constatação da natureza e quantidade da droga nº 415.651/2021 (fls. 17/20), pelo laudo pericial definitivo nº 416.862/2021 (fls. 132/134) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria da infração penal também foi atestada por meio da prova oral colhida em juízo.

Adiante, passo à descrição da prova oral produzida ao longo da audiência de instrução.

Giovane de Souza da Silva, policial militar, testemunha das partes, em juízo, disse que estava em patrulhamento pelo Largo São Bento, em conjunto com o seu parceiro, quando, ao passarem pela Praça Ouvidor Pacheco e Silva, avistaram o réu, que

visualizou a viatura policial, demonstrou nervosismo e arremessou uma sacola preta bem próxima a um poste, o que motivou a abordagem. Seu parceiro, ao realizar a busca pessoal, encontrou uma certa quantidade de entorpecente e um telefone celular no bolso do réu. Já na sacola preta que havia sido arremessada, encontraram mais lança perfume e mais entorpecentes. Foram localizadas maconha, cocaína e lança perfume. A cocaína estava separada. O réu assumiu que estava traficando drogas pois estava passando por necessidade.

Felipe de Palma Medeiros, policial militar, testemunha das partes, em juízo, disse que estava em patrulhamento, junto com o soldado Giovane, quando avistaram na praça um indivíduo que dispensou uma sacola preta. Tal ato gerou uma certa desconfiança por parte da equipe. Ademais, o local trata-se de um ponto de tráfico de drogas. Portanto, decidiram por abordar o indivíduo. Foi encontrada uma quantidade de drogas e dinheiro nos seus bolsos. Na sacola preta que havia sido dispensada, havia porções de lança perfume. O réu não resistiu à prisão e confessou a prática do tráfico de drogas. Foram encontrados, ao todo, no bolso direito do réu, cinco papelotes de cocaína e dez porções, aparentemente de maconha, no bolso esquerdo, R\$ 74,00 em dinheiro, e na sacola preta, dez frascos de lança perfume.

Francisco Alexandre Souza Viana, réu, em seu interrogatório, disse que estava voltando do serviço. Trabalha descarregando caminhão no mercadão. Como é usuário, passou na biqueira para comprar cinco porções de cocaína. As porções de maconha e lança perfume não foram encontradas consigo. Os fatos ocorreram às 06h20min, e não às 07h20min.

Concluída a descrição da prova oral coletada em juízo, saliento que a versão apresentada pelo réu, em seu interrogatório, restou isolada nos autos.

E ressalte-se, não há nos autos nenhum elemento que identifique a intenção dos policiais militares em prejudicar o réu. Pelo contrário, o relato dos policiais guarda precisão com as demais provas colhidas.

Destaco que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, pois presente o réu e seu defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado conceder aos agentes de segurança pública crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.

APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ - Potencialidade lesiva das munções constatada por laudo pericial - Necessária a

desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido.

Por conseguinte, a palavra dos policiais e o laudo pericial definitivo nº 416.862/2021 (fls. 132/134) são provas suficientes de que o acusado trazia consigo cocaína, maconha e lança perfume sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acresça-se que, de acordo com a fotografia de fls. 30, a quantia de R\$ 74,00 apreendida com o réu estava fragmentada em diversas cédulas de R\$ 2,00, R\$ 5,00 e R\$ 10,00. E como é cediço, os traficantes que atuam no varejo, devido ao fato de venderem para pequenos consumidores, trazem consigo determinada quantia em dinheiro fracionada em pequenos valores com o propósito de fornecer troco e assim facilitar o desenvolvimento da atividade comercial ilícita.

Ademais, convém ressaltar que a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado é incomum a um usuário, mas não a um traficante, o que apenas reforça o seu propósito mercantil.

Por fim, aponto que embora o réu, em juízo, tenha assumido tão somente a posse da cocaína apreendida e justificado que a teria adquirido para consumo próprio, não apresentou qualquer justificativa quanto à sua declaração perante a autoridade policial, oportunidade em que admitiu que estava vendendo todos os entorpecentes apreendidos.

Logo, reputo o conjunto probatório robusto o suficiente para ensejar um decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas.

Demonstrada a prática de fato típico, ilícito e culposo pelo réu, passo a dosar a pena:

Primeira fase: Analiso individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: Apreciarei a reprovabilidade da conduta do réu apenas quando da aplicação do quantum da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a fim de evitar o bis in idem.

B) Antecedentes: O réu não ostenta maus antecedentes, consoante a certidão estadual de distribuições criminais às fls. 36/37, não cabendo o agravamento da pena.

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu, não cabendo o agravamento da pena.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: Ausentes circunstâncias do crime que justifiquem o agravamento da pena.

G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: O crime não possui vítima determinada.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: Embora o Ministério Público tenha sustentado que o réu é reincidente específico, a certidão estadual de distribuições criminais às fls. 36/37 aponta que o acusado não foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas, visto que a última movimentação revela a interposição de recurso pela defesa. Portanto, inviável o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

Quanto à circunstância atenuante da confissão, reconheço-a devido à confissão do réu perante a autoridade policial, também utilizada para o convencimento deste julgador para o decreto condenatório, vide súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça;

Entretanto, há de ser observada a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a circunstância atenuante não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal.

Da análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, fixo, na segunda fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o referido dispositivo legal estabelece quatro requisitos cumulativos para que o réu possa fazer jus à causa de diminuição de pena: ser o agente primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Consoante a certidão estadual de distribuições criminais de fls. 36/37, o réu é primário e possui bons antecedentes.

No que tange à não dedicação a atividades criminosas, compreende-se que o réu deve desenvolver algum tipo de atividade profissional lícita e habitual, não apresentando uma personalidade direcionada à criminalidade. Ou seja, o crime de tráfico de drogas imputado ao réu deve ser compreendido como um evento excepcional em sua vida. Deste modo, se demonstrado que o réu integra associação voltada para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei nº 11.343/06) ou associação criminosa (artigo 288, do Código Penal), não será devida a incidência da minorante. Da mesma maneira, se o réu for flagrado com vasta quantidade e variedade de drogas, tem-se como caracterizada a dedicação a atividades criminosas, visto que incompatíveis a um traficante pequeno e eventual. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu mais recentemente orientação jurisprudencial no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante sob análise por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

Pois bem, não constam nos autos do presente processo qualquer prova no sentido de que o réu integrasse na data do fato associação para o tráfico de drogas ou associação criminosa. Também, não é possível afirmar que o réu mantinha consigo quantidade tão vasta e variada de drogas a ponto de concluir que se trata de um traficante não eventual. Por fim, inexistente certidão estadual de distribuições criminais de ações da infância e da juventude infracional em nome do réu. Portanto, preenchido o terceiro requisito.

Quanto ao quarto e último requisito, é oportuno mencionar a norma ínsita no artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, que conceitua como organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. No presente caso, a análise dos autos não permite inferir que o réu integrasse organização criminosa na data do fato. Por conseguinte, atendido o quarto requisito.

Preenchidos todos os requisitos, é imperiosa a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em favor do réu.

Em relação ao quantum da causa de diminuição da pena sob análise a ser aplicada, pondero que o laudo pericial de constatação da natureza e quantidade da droga 415.651/2021 (fls. 17/20), posteriormente ratificado pelo laudo pericial definitivo nº 416.862/2021 (fls. 132/134), revela que o réu trazia consigo 2,4g (dois vírgula quatro gramas) de cocaína, 17,2g (dezessete vírgula dois gramas) de maconha e 90ml (noventa mililitros) de lança perfume. Conquanto se trate de uma quantidade reduzida de substâncias entorpecentes, dada a natureza da cocaína, droga esta que possui alta capacidade de causar dependência química assim como um elevado potencial lesivo, podendo inclusive matar quem a consome, e ainda, a variedade de drogas apreendidas com o acusado, diminuo a pena em 1/6 (um sexto).

Da análise das causas de aumento e diminuição da pena, fixo, na terceira fase, a pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Semiaberto, conforme o disposto no § 2º, alínea "b", do artigo 33, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito

(artigo 44 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena (artigo 77, Código Penal): Inadmissível pois o réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos (artigo 77, caput, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 43, da Lei nº 11.343/2006): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu Francisco Alexandre Souza Viana à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo federal vigente ao tempo do fato, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c.c. o § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Tendo restado comprovada a materialidade e a autoria (fumus comissi delicti) de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos, e diante da necessidade de garantia a ordem pública, visto que ostenta reiteração delitiva em crimes dolosos (periculum libertatis), mantenho a prisão preventiva do réu com fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Entretanto, considerando a pena imposta nesta sentença condenatória, o regime inicial fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade e o princípio da homogeneidade, determino a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, com fundamento nos artigos 804, do Código de Processo Penal, e 1.094, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Declaro o perdimento dos bens apreendidos com o réu em favor da União, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

Em havendo droga apreendida remanescente, proceda-se à sua destruição.

Expeça-se o necessário.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA